

<제2편 소송의 주체.제04장 당사자.제02절 당사자의 자격>

[기출][2021-2]당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

《【문제2】 당사자능력에 대하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 당사자능력의 의의, 판정 기준, 비법인의 당사자능력, 당사자능력의 흠결과 효과

I. 문제의 제기

- 당사자능력이란 소송의 주체가 될 수 있는 일반적인 능력을 의미하며, 이는 민법상 권리능력에 대응하는 개념이다. 소송절차의 안정성과 실효성을 확보하기 위해 누가 소송의 당사자가 될 수 있는지를 확정하는 것은 소송요건 중 가장 기초적인 단계에 해당한다. 민사소송법은 원칙적으로 민법상 권리능력자에게 당사자능력을 인정하나, 소송의 편의를 위해 법인이 아닌 사단이나 재단에 대해서도 일정한 요건 하에 당사자능력을 예외적으로 인정하고 있다. 당사자능력은 소송의 전 과정에서 유지되어야 하는 직권조사사항이며, 이를 결여한 소송행위는 원칙적으로 무효이다. 이하에서는 당사자능력의 구체적인 판정 기준과 비법인 사단의 당사자능력, 능력이 흠결된 경우 법원이 취해야 할 조치를 중심으로 설명한다.

II. 당사자능력의 판정 기준

1. 자연인

- 모든 자연인은 생존하는 동안 당사자능력을 가진다. 국적이냐 연령, 정신상태와 관계없이 인격을 가진 존재라면 누구나 소송의 당사자가 될 수 있다.

(1) 태아의 당사자능력

- 태아는 원칙적으로 권리능력이 없으므로 당사자능력도 부정된다. 판례는 태아가 소송을 제기하기 위해서는 살아서 출생해야 한다는 정치조건설의 입장을 취하므로, 태아인 상태에서 제기된 소는 부적법하다.

(2) 외국인의 당사자능력

- 외국인도 자연인인 이상 당사자능력을 가진다. 다만, 소송비용 담보제공 등의 제한이 따를 수 있으나 능력 자체는 부정되지 않는다.

2. 법인

- 법인은 설립등기를 마침으로써 권리능력을 취득하며, 동시에 당사자능력을 가진다. 영리법인, 비영리법인, 공법인(국가, 지방자치단체) 모두 포함된다.

(1) 국가 및 지방자치단체

- 국가는 사법관계에서도 당사자능력을 가지며, 지방자치단체 역시 공법인으로서 당사자능력을 인정받는다. 그러나 지방자치단체의 하부조직인 동이나 면은 원칙적으로 당사자능력이 없다.

(2) 청산 중의 법인

- 법인이 해산되더라도 청산 사무가 완료될 때까지는 청산의 목적 범위 내에서 당사자능력을 유지한다.

III. 비법인 사단 및 재단의 당사자능력

1. 의의 및 인정 근거[민사소송법 제52조]

- 법인이 아닌 사단이나 재단이라도 대표자나 관리인이 정해져 있는 경우에는 그 이름으로 소송의 당사자가 될 수 있다. 이는 실질적으로 사회적 활동을 수행하는 단체의 소송 편의를 도모하기 위함이다.

2. 인정 요건

(1) 사단의 실체

- 단체로서의 조직을 갖추고 있고, 의사결정기관과 집행기관인 대표자가 선임되어 있어야 하며, 구성원의 변경과 관계없이 단체 자체가 존속되어야 한다.

(2) 독립된 재산의 존재

- 단체 고유의 목적을 달성하기 위한 독립된 재산이 형성되어 있어야 한다.

3. 구체적 사례에 대한 판례의 태도

(1) 중증

- 중증은 특별한 조직 행위가 없어도 공동조상의 후손들에 의해 당연 성립하는 종족 단체로서, 대표자가 선임되어 있다면 당사자능력이 인정된다.

(2) 학교

- 학교는 시설물에 불과하므로 당사자능력이 없다. 소송을 제기하려면 학교를 운영하는 법인이나 경영자를 당사자로 해야 한다.

(3) 조합

- 민법상 조합은 원칙적으로 당사자능력이 없다. 따라서 조합원 전원이 공동으로 소송을 수행하거나 선정당사자 제도를 활용해야 한다. 다만, 실무상 재건축조합 등은 비법인 사단의 실체를 갖춘 경우 민사소송법 제52조에 의해 당사자능력이 인정되기도 한다.

IV. 당사자능력의 흠결과 소송법적 효과

1. 직권조사사항

- 당사자능력의 존부는 법원의 직권조사사항이다. 당사자의 항변이 없더라도 법원은 이를 스스로 조사하여야 하며, 상고심에서도 새로운 증거를 통해 이를 판단할 수 있다.

2. 소송계속 전후의 흠결

(1) 소 제기 당시부터 흠결된 경우

- 소 제기 당시에 이미 당사자능력이 없는 자를 상대로 하거나 그 명의로 제기된 소는 부적법하므로 법원은 소각하 판결을 내려야 한다. 다만, 보정이 가능한 경우에는 보정을 명할 수 있다.

(2) 소송 진행 중 흠결된 경우(당사자의 사망 등)

- 소송 도중 당사자가 사망하거나 법인이 해산된 경우에는 소송절차가 중단되며, 상속인이나 합병 후의 법인이 소송을 수계하여야 한다.

3. 당사자표시정정과의 관계

- 당사자를 잘못 지정했으나 실질적으로 동일성이 인정되는 경우에는 당사자표시정정을 통해 하자를 치유할 수 있다. 그러나, 동일성이 인정되지 않는 전혀 다른 사람으로 정정하는 것은 허용되지 않는다.

V. 결론

- 당사자능력은 소송절차의 유효한 성립을 위한 필수적 전제 요건이다. 민사소송법이 비법인 사단에 대해 당사자능력을 인정하는 것은 현대 사회의 다양한 단체 활동을 소송법적으로 수용하기 위한 합리적인 조치이다. 법원은 당사자능력의 유무를 엄격히 심사하여 부적법한 소송에 의한 사법 자원의 낭비를 막아야 하며, 동시에 당사자표시정정이나 보정 명령 등을 적절히 활용하여 당사자의 재판받을 권리가 절차적 형식주의에 의해 침해되지 않도록 균형을 유지해야 한다.